

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 6a Nominación de Córdoba

Remigio, Rubén A. y otra • 18/10/1991

2ª Instancia.- Córdoba, octubre 18 de 1991.

1ª ¿Es justa la sentencia apelada? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión.- El doctor La Piña dijo:

1) Rubén A. Remigio, empleado del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, y su esposa, Irene G. Marcuzzi, empleada a su vez de la Dirección General de Rentas, promueven acción de amparo frente a la Provincia de Córdoba, persiguiendo la admisión de su hijo Rubén R. en la guardería judicial. Manifiestan, a título de fundamentos de la pretensión que la resolución denegatoria adoptada en su oportunidad por la Administración es manifiesta y evidentemente ilegal toda vez que la situación del menor encaja exactamente en una de las hipótesis fácticas captadas por la ley 7749 y el Acuerdo Reglamentario 153-Serie C, según la cual la guardería puede ser utilizada por todos los hijos menores de 5 años del personal masculino cuando carezca de guardería el lugar de trabajo de la madre. En subsidio, para el caso de que se entendiese que el niño no queda comprendido en el texto legal, plantean la inconstitucionalidad del art. 2º de la ley en cuanto

consagra una discriminación arbitraria e irrazonable. Advierten acerca de la magnitud e irreparabilidad del daño que un cambio de entorno le podría acarrear al menor. Invocan el quebrantamiento de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso, vida, personalidad, propiedad, igualdad, así como de los principios de legalidad y supremacía constitucional. Piden costas. 2) El juez de primer grado hizo lugar a la acción incoada y, en consecuencia, ordenó la admisión del menor en la guardería. 3) La Provincia apeló la sentencia y, pide el rechazo de la demanda entablada, con costas, fundada en los siguientes agravios que expone: a) El amparo es formalmente inadmisibile pues fue promovida fuera del término prescripto por el art. 2 inc. e de la ley 4915, modificada por la 5770: "...el hecho fáctico denegatorio del derecho que se reclama en autos, aconteció al denegárseles a los actores la inscripción de su hijo en diciembre de 1989 y que en defecto de notificación forma, debemos computar, desde que la persona se manifestaba sabedora del acto, es decir del 5 de enero de 1990, cuando interpone su extensísimo reclamo administrativo y medida de no innovar..." (sic). b) No se ha demostrado acabadamente la falta de aptitud de las vías administrativas previas para tutelar el supuesto derecho invocado; por lo cual lo aseverado en contrario por el sentenciante constituye una afirmación dogmática desprovista de sustento fáctico. c) Tampoco se ha acreditado la existencia del daño o gravamen irreparable cuya protección se reclama, lo que configura un obstáculo insalvable para la procedencia del amparo. d) De acuerdo a las Constituciones Nacional y Provincial los derechos se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; de modo

que no cabe reconocer derechos absolutos e imperativos, sino sujetos a la posibilidad cierta y tangible de hacer viable la tutela perseguida. En el caso particular, "... la protección del texto legal va dirigida a la madre trabajadora y en segundo lugar, si las condiciones de salubridad, seguridad, pedagógicas, etc. lo permiten, hacia los trabajadores varones, sin que ello presuponga discriminación de ninguna índole..." (sic.). 4) Los amparistas, por su parte, han petitionado la confirmación de la sentencia en recurso, con costas, formulando al propio tiempo reserva de Caso Federal y el Asesor Letrado de 9º turno, finalmente, reclama la deserción de la apelación, en la inteligencia que el libelo de expresión de agravios no contiene una crítica razonada del pronunciamiento impugnado. 5) La sentencia bajo examen abarca una relación de la causa que se adecua a la exigencia del art. 350 del Cód. de Proced. Civil; a ella me remito y ha de entenderse que se reitera aquí. Mientras, los ataques concretados los analizaré en el marco que conforma el art. 353, ibídem. 6) Habida cuenta la naturaleza excepcional de la vía elegida, corresponde, ante todo, me expida respecto a la procedencia formal de la acción que ha sido motivo de ataque por el apelante. Es conocido que la acción de amparo requiere, para su procedencia, en principio, que el acto u omisión que se denuncia esté viciado de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, que surja con nitidez del curso de un breve debate; que no existan o no hayan sido usados otros mecanismo administrativos o judiciales que permitan obtener la protección de los derechos constitucionales que se dicen vulnerados y que no se requiera mayor amplitud de discusión o prueba o la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Afirmadas

estas premisas liminares y desde las perspectivas que ellas ofrecen, sostengo que la vía intentada por Remigio, el amparo, resulta, a la fecha de su promoción (22/3/90), formalmente inadmisible, desde que en dicha oportunidad los interesados tenían a su alcance e hicieron uso, de otras vías paralelas administrativas para la elucidación del conflicto, lo cual constituía un obstáculo para la procedencia de esta vía excepcional, conforme las prescripciones del art. 2º inc. "a" de la ley 4915. En efecto, tal cual lo reconocen los propios amparistas a fs. 27/33 y el a quo a fs. 129/30, en contra del Acuerdo núm. 4, sección "C", del 14 de febrero de 1990, se interpuso aclaratoria y un recurso de nulidad con fecha 8 de marzo de 1990, los que fueron resueltos; conforme a la ley de trámite administrativo, por Acuerdo núm. 16, serie C, el 27/3/90, del que fuera notificado Remigio el 6 de abril de 1990, tal cual surge de la constancia de fs. 112 vta. Es decir que a la fecha de la promoción del amparo -22/3/90 aún no estaba resuelta la nulidad intentada por los actores, como bien lo señala el a quo a fs. 129, recurso procesal pertinente que al aparecer como dirigido a atacar el decisorio que lo agravaba (acuerdo núm. 4) para tutelar de esa manera sus derechos, esto es como un remedio apto para la solución del conflicto que los aqueja, les enervaba la posibilidad de promover, al propio tiempo pendiente la resolución, el amparo que ahora estoy examinando, ya que, a mi criterio, aquel remedio era suficientemente apto para la solución del conflicto. Los actores, se advierte con nitidez, por un acto de propia decisión, recurrieron lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia por lo que la vía adoptada no es susceptible de marginación para reemplazarla luego

por la demanda de amparo. En otras palabras, la causa pendiente antes aludida le impedía a Remigio la promoción del amparo. Y en esto discrepo en forma absoluta con lo sostenido por el a quo, quien no obstante reconocer a fs. 129 vta. que ésa es la doctrina de la SCJN (LA LEY, 1985-C,140). En efecto; para apartarse de la ley y de la doctrina de la Corte, el judicante echa mano de un párrafo aislado de Rivas que no es de aplicación al caso si se tiene en cuenta que dicho autor pone como condición para desviarse de la exigencia legal, "la acabada demostración" en el amparo de la falta de aptitud del recurso pendiente para operar la adecuada tutela del derecho, lo cual no ha sido objeto de prueba de parte de los interesados, por lo que la decisión del a quo se presenta como vacía, sin sustentos fácticos ni jurídicos("El amparo", p. 141). La Corte, sostiene dicho autor, en los autos "Hughes Tool Company S.A. c. Gobierno Nacional" revocando una decisión de la CN de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había sostenido que al agotamiento de la vía administrativa pendiente utilizada al propio tiempo que el amparo resultaba un "ritualismo inútil", estimó que tal conclusión se basaba, como en este caso, en una mera conjetura ya que no se podía sustentar el abandono de ese camino en el "ritualismo" afirmado (ob. cit. p. 147). En el sentido que me pronuncio, Sagüés es terminante cuando se refiere a la vía administrativa paralela al amparo. Y al respecto dice que cuando la autoridad pública adopta una decisión, el ordenamiento legal prevé ciertos mecanismos a través de los cuales puede impugnarse ese pronunciamiento. Mientras no se agoten esos trámites, el acto cuestionado no está firme, lo cual impide interponer un amparo en sede judicial, al

no "transitar previamente" al decir de Bidart Campos, "las instancias ordinarias de reparación" (Sagüés, "Acción de Amparo", p. 177 y Bidart Campos, "Régimen Legal", ps.165 y 197), que resulta obvio, los actores no recorrieron. Agrega Sagüés que el amparo no puede ser admitido si se encuentra pendiente de sustanciación definitiva un recurso interpuesto por el interesado (LA LEY, 1975-13, 1980) o hay remedios o peticiones administrativas en trámite, como en este caso (obr. cit., p. 179), principio rector éste que admite excepciones, únicamente, como dije, no sólo cuando se demuestre en autos -lo que aquí no ha acontecido la ineficacia cierta del procedimiento administrativo que transformaría el requisito del agotamiento de la vía administrativa en un formalismo o ritualismo inútil, sino también cuando hubiera mediado mora en la resolución o cuando el actor acredite que la consecución del trámite le irroga un agravio la imposible reparación ulterior (obr. cit., ps. 182/3). Surge claro de la sentencia que ninguna de tales excepciones han sido acreditadas por las partes ni menos invocadas por el sentenciante ya que, para salirse de los carriles legales, efectúa tan sólo una mera afirmación subjetiva. Por otra parte, el que antecede es el temperamento que sustenta el TSJC cuando se sostuvo que para el juez a través del amparo se aparte del principio general receptado por la norma del art. 2º inc. 1º de la ley 4915, dejando de lado la vía paralela correspondiente a la protección del derecho en cuestión, se debe estar ante una ilegitimidad manifiesta y un grave daño que ocasionaría al interesado someterse a los procedimientos ordinarios, por lo que debe acreditarse la ineptitud de los remedios ordinarios (Herrera, Ana; "amparo", Sent. 16/2/90). Por lo que he

dicho voto para que se revoque la sentencia por entender que del análisis del caso concreto, no se dan ni han sido acreditadas, ninguna de las excepciones que le hubieran permitido al a quo abrir el amparo estando pendiente la resolución administrativa (SCJN; 295:25; 297:93; 298:329; 303:419), es que a mi entender, en el caso no median causas graves que incidan en el menoscabo de un derecho amén de que si todos los empleados siguieron el camino de los actores, no tendría sentido la evaluación anual de ingreso que prevé la ley 7249. A los restantes agravios no los analizo, habida cuenta de la postura que adopto. 7) Por último, estimo que el proceso del amparo, como lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, no es la vía idónea para juzgar la inconstitucionalidad de las leyes, ya que por su carácter sumario, excepcional, extraordinario y no contradictorio, carecería de eficacia para acumular el material necesario y resolver una cuestión de esa naturaleza, la que requiere de un debate más extenso del que permite un procedimiento de esas características. (SCJN, "Couto c. Estado nacional. Sent. del 20/12/86) y siguiendo tal doctrina, acoto, que tal imposibilidad de hecho existe concretamente en el caso de autos que reputo ha menester, para expedirme sobre la inconstitucionalidad de los arts. 1º y 2º de la ley 4915 y art. 2º de la ley 7249, se requiere una investigación fáctica impracticable en la especie (Video Visión c. Municipalidad de Córdoba, sala Civil, Sent. 23/12/86). 8) En punto a costas, debe soportarlas la parte actora, en ambas instancias, conforme el resultado que propugno. Voto, pues, por la negativa.

El doctor Lavisse dijo:

Que adhería a lo expresado por el vocal preopinante, votando en igual sentido a esta cuestión propuesta ya que comparte los fundamentos.

La doctora Montoto de Spila dijo:

Que adhería a lo expresado por el vocal preopinante, votando en igual sentido a esta cuestión propuesta ya que comparte los fundamentos.

2ª cuestión.- El doctor La Peña dijo:

Corresponde acoger la apelación; revocar la sentencia; desestimar el amparo e imponer las costas a los actores, en ambas instancias, difiriendo la estimación de honorarios.

El doctor Lavisse dijo:

Que adhería a lo expresado por vocal preopinante, votando en igual sentido a esta cuestión propuesta ya que comparte los fundamentos.

La doctora Montoto de Spila dijo:



Que adhería a lo expresado por el vocal de primer voto, votando en igual sentido a esta cuestión propuesta ya que comparte los fundamentos.

Por el resultado de la votación que antecede, se resuelve: 1) Acoger la apelación. 2) Revocar la sentencia. 3) Desestimar el amparo e imponer las costas a los actores, en ambas instancias.-

José de La Peña.- Jorge R. Lavissee.- Marta Montoto de Spila.- Ante mí: Celina Conci de Busleiman.